

## 第23問

医者である甲は、甲の妻と不倫をしているAがたまたま自己の経営する病院に入院してきたことから、これを機に、Aを殺害しようと考えた。そこで、甲は、看護師の資格を取ったばかりであって、甲の病院に勤務し始めて間もない乙に対して、「この点滴をAさんに投与してください。」などと言って、毒薬を手渡した。乙は、過去に一度だけ甲の指示に従って点滴をしたことがあったため、今回も同様であろうと考え、これを受け取り、Aの病室へと向かった。乙は、Aの寝ているベッドの脇で点滴をする準備をしていたところ、前日、たまたま医学雑誌で見た毒薬と甲から手渡されたものが合致していることに気が付き、これが毒薬であることが分かった。乙は、これに戸惑ったものの、Aの入院中にセクハラの被害を受けていたことから、この毒薬で殺してしまおうと考え、Aに毒薬を投与し、Aを死亡させた。

その後、乙が、Aの鞆の中を一瞥したところ、Aの財布を発見した。乙は、財布からお金を抜き取っても、誰も分からないだろうと考え、Aの財布から3万円を抜き取った。

甲及び乙の罪責について論じなさい。

## 第1 乙の罪責

- 1 まず、乙に殺人罪（199）が成立することは明らかである。なお、乙は、A殺害時には、財布から現金を抜き取ることは考えていなかったから、強盗罪（236）は成立しない。
- 2 Aの財布から現金3万円を抜き取った行為が、窃盗罪（235）となるか、占有離脱物横領罪（254）となるか。いわゆる死者の占有の問題である（**論点** 死者の占有  司H29）。

判例（最判昭41.4.8【百選Ⅱ29】）は、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である」として、自ら被害者を殺害した者との関係では、窃盗罪を肯定する。

したがって、これに従えば、乙に窃盗罪が成立する。

 総合 197 頁  論証 83 頁

## 第2 甲の罪責

まず、甲は、乙をしてAに毒薬を投与させ、殺害させようとしていることから、殺人罪（199）の間接正犯が成立しないかが問題となる（**論点** 間接正犯の成否  司H25,予H29,R4,I,H10-1,H17-2,H18-1）。

次に、甲は、間接正犯の故意で乙をしてAに毒薬を投与させようとしたが、乙は甲の意図に気付きつつも、Aに毒薬を投与し死亡させている。そうすると、甲の主観面としては、間接正犯の故意であるが、客観面は教唆行為を行っているということになる。そこで、間接正犯と錯誤の問題が生じる（**論点** 間接正犯と錯誤  司H21,H25,I,H10-1）。

このような事案では、間接正犯の故意で教唆犯（61 I）の結果を生じさせたとして、抽象的事実の錯誤の問題と捉え、殺人既遂罪の教唆犯となるとするのが通説的である。

なお、間接正犯の実行の着手時期（**論点** 間接正犯の実行の着手時期  予R4,I,H2-1,H10-1）に応じて、殺人未遂罪（203、199）の間接正犯が成立し、殺人既遂罪の教唆犯と観念的競合（54 I 前段）となるとする立場もある。

 総合 120 頁  論証 47 頁

 総合 127 頁  論証 48 頁

 総合 127 頁  論証 48 頁

## 答案構成

### 第1 乙の罪責

#### 1 殺人罪（199）成立

↓

#### 2 窃盗罪（235）の成否

↓

死者の占有

↓

自ら被害者を殺害した者との関係では、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有を侵害するものと評価できる

↓

あてはめ

↓

窃盗罪成立

↓

#### 3 殺人罪と窃盗罪は併合罪（45前段）となる

### 第2 甲の罪責

#### 1 殺人罪（199）の間接正犯の成否

↓

行為支配性、正犯意思の2つの要件が必要

↓

あてはめ

↓

殺人既遂罪の間接正犯不成立

↓

殺人未遂罪の間接正犯も成立しない

↓

#### 2 客観的には教唆犯（61 I）となる

↓

間接正犯の故意で、教唆犯を犯した場合の処理

↓

教唆犯として処断する

↓

甲に殺人既遂罪の教唆犯が成立する

## 第1 乙の罪責

1 乙が殺意をもって毒薬をAに投与して死亡させた行為については、  
「人を殺した」ものとして、殺人罪（199条）が成立する。

2(1) 次に、Aの財布から現金3万円を抜き取った行為であるが、これに  
は「他人の財物を窃取した」として、窃盗罪（235条）が成立する  
可能性がある。なお、強盗罪（236条1項）の成立余地はない。強  
盗罪は暴行・脅迫を手段として他人から財物を強取することにその本  
質がある以上、暴行・脅迫時点において財物奪取の意思が必要だから  
である。

(2) もっとも、「窃取」とは意思に反した占有移転をいうところ、Aが  
既に死亡しているため、Aの占有が認められないのが原則であり、し  
たがって、占有移転も認められないのが原則である。死者には、占有  
の意思も事実もないからである。

しかし、自ら被害者を殺害した者との関係では、殺害から財物奪取  
までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有を侵害するものと評  
価できる。

本問では、Aを殺害した乙が、その直後にAの財布から現金を抜き  
取っているのであるから、一連の行為を全体的に観察すれば、乙の行  
為は、Aの生前の占有を侵害したといえる。

(3) したがって、「他人の財物を窃取した」といえ、故意（38条1  
項）及び不法領得の意思に欠けるところはないから、乙には窃盗罪が  
成立する。

1

3 以上より、殺人罪と窃盗罪が成立し、両罪は併合罪（45条前段）と  
なる。

## 第2 甲の罪責

1(1) 甲は、乙をしてAに毒薬を投与させ、殺害させようとしているが、  
かかる行為について殺人罪（199条）の間接正犯が成立する可能性  
がある。

(2) ここで、正犯とは自らの意思で犯罪を実現し、第一次的な責任を負  
う者であるから、直接手を下さなくとも被利用者を通して因果経過を  
実質的に支配し、自己の犯罪事実実現の目的を遂げた者もまた正犯と  
することに問題はない。

したがって、行為者が被利用者に対して行為支配性を有しているこ  
と、他人の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有しているこ  
との二つの要件を満たす場合には、この者を間接正犯として処罰する  
ことができると解する。

(3) 本件では、乙は、Aの寝ているベッドの脇で点滴をする準備をして  
いたところ、前日、たまたま雑誌で見た毒薬と甲から手渡されたもの  
が合致していることに気が付き、これが毒薬であると分かっている。  
そして、独自にAの殺害を決意したのであり、甲の乙に対する行為支  
配性は完全に失われているといえる。

したがって、本件では甲に殺人既遂罪の間接正犯は成立しない。

なお、殺人未遂罪の間接正犯も成立しないと考えるべきである。実  
行の着手時期（43条本文）は、法益侵害の現実的具体的危険性が発

2



生した時点に求められるべきところ、利用者が利用行為を開始した時点では、そのような危険性が認められないからである。

2(1) 一方で、客観的には、甲は、「人を教唆して犯罪を実行させた」ものとして、教唆行為（61条1項）を行っていることになる。

(2) では、間接正犯の故意で、教唆犯を犯した場合、いかに解すべきか。

ここで、故意責任の本質は犯罪事実の認識によって反対動機が形成できるのに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。そして、犯罪事実は刑法上構成要件として類型化されているから、構成要件該当事実の認識がなければ反対動機の形成可能性がなく、原則として故意は阻却されるということになる。

ただし、構成要件に実質的な重なり合いが認められる場合には、その限度で反対動機を形成することができる。したがって、そのような場合には、その限度で故意責任を問うことができると考える。具体的には、認識と事実との間に重なり合いの認められる限度で罪責を負うとすべきである。

そして、間接正犯と教唆犯とは他人を利用して法益侵害の結果を発生させる点に客観面における共通点が認められ、間接正犯の故意は教唆犯の故意を含むというべきである。一方で、間接正犯は教唆犯よりも犯情の点で重い。

したがって、軽い教唆犯の限度で処断するのが妥当である。

(3) 本件でも、甲には殺人既遂罪の教唆犯が成立する。

3

以上

4